

1500885-52.2020.8.26.0417

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALINE AMARAL DA SILVA

Comarca: Paraguaçu Paulista

Foro: Foro de Paraguaçu Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/06/2022

... REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. ADEMAIS, SUPERVENIÊNCIA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE SUPERADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica e uníssona desta Casa é no sentido de que o delito de tráfico de entorpecentes, nas modalidades guardar, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paraguaçu Paulista

Foro de Paraguaçu Paulista

2ª Vara

Avenida Siqueira Campos, 1429, Paraguacu Paulista-SP - cep 19700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500885-52.2020.8.26.0417 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500885-52.2020.8.26.0417

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2266931/2020 - DEL.POL.PARAGUACU PAULISTA, 14364862 - DEL.POL.PARAGUACU PAULISTA, 780/20/113 - DEL.POL.PARAGUACU PAULISTA, 2266931 - DEL.POL.PARAGUACU PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDREIA APARECIDA MASSE ORTIZ e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE AMARAL DA SILVA

Vistos.

ANDRÉIA APARECIDA MASSE ORTIZ e EDUARDO APARECIDO MASSE DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, "caput", e art. 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, em concurso material de infrações, na forma do artigo 69 do Código Penal, pois, em tese, no dia, 27 de outubro de 2020, por volta das 10h40min, na Rua Felício Tarabay, nº 1250, Barra Funda, neste município e comarca, (i) associaram-se para juntos praticarem, reiteradamente, o crime de tráfico de Drogas, e (ii) venderam 01 (uma) pedra de crack, com massa líquida de 0,19g, e tinham em depósito mais 97 (noventa e sete) pedras de crack, com massa líquida de 19,78g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente notificados, os réus apresentaram defesa preliminar às fls. 217/219 e 300/301.

A denúncia foi recebida em 25 de novembro de 2020 e, ante ausência de causas para absolvição sumária, determinado o prosseguimento do processo (fls. 169/171).

Na audiência de instrução, foram ouvidas três testemunhas, dois informantes e, ao final, os réus foram interrogados.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu Eduardo Aparecido Masse de Oliveira e a absolvição da ré Andréia Aparecida Masse Ortiz. Na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias do art. 59 do CP são favoráveis ao réu, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal. Na segunda fase, presentes as atenuantes de confissão e menoridade. Na terceira fase, presente a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que indicam que o réu trabalha. Pena deverá ser cumprida em regime fechado. Impossibilidade da substituição da pena corporal pela restritiva de direitos (fls. 394/401).

A Defesa apresentou alegações finais escritas requerendo a absolvição de Andréia, no tocante a ambas imputações, em razão da insuficiência probatória. Quanto a Eduardo, argumentou o ingresso desautorizado no domicílio, tornando a prova nula, sendo a absolvição medida de rigor. Caso não seja o entendimento pela absolvição, na primeira fase da dosimetria, a pena base deve ser fixada no mínimo legal. Na segunda fase, presentes as atenuantes de confissão e menoridade. Na terceira fase, presente a causa de diminuição, pois o réu trabalha (fls. 405/414).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva ficou demonstrada no Auto de Prisão em Flagrante (fls. 1), Termos de Depoimento (fls. 2/6), Termos de Interrogatório (fls. 7/8), Boletim de Ocorrência (fls. 9/12), Auto de Exibição/Apreensão (fls. 13/16), Laudo Pericial (fls. 52/56 e 118/120), Relatório Final (fls. 125/128), bem como nas demais provas produzidas em juízo.

A autoria delitiva pode ser seguramente atribuída ao acusado Eduardo Aparecido Masse de Oliveira.

O informante, Edvaldo Antonio da Silva disse que se quisesse rocha, sai daqui e vai procurar em outro canto; que, no dia, comprou droga lá, do Eduardo; que pagou R\$ 10,00; que a Andréia nem tava lá; que ele falou que está moído se a mãe dele estiver lá; que essa foi a primeira vez; que comprou a droga na janelinha da casa; que pediu pinga e ele disse que tinha rocha; que ele pediu outra e ele disse que estava moído; que o bar estava fechado; que a apreensão foi subindo, uns 50 metros para cima; que a hora que viu o policial, o cacete bateu na mão e falou que tinha comprado do muleque; que eles foram na frente; com uma espingarda; foi dois na frente; que falaram para entrar e colocaram na parte de trás; que escutou o barulho do portão; que estava deitado no curralzinho.

A informante, Jessica Aparecida Coelho disse que tinha acabado de chegar para poder limpar o bar; que chegaram os homens da máquina para arrumar a máquina de música e de sinuca; que estavam dentro do bar; que escutou um barulho; que a polícia veio algemando ela; que pegou a criança do colo dela; que o bar não estava aberto ainda; que escutaram um barulho; que no bar, tem uma porta que dá acesso para dentro da residência; que, depois de algemada, levaram ela para dentro falando que tinham achado um pote; que ela pulou no pote; que ela ficou surpresa com o fato de o filho

estar traficando; que o Eduardo corta cabelo; que ali não é um ponto de drogas; que o pote estava dentro da casa; que não viu de onde os policiais tiraram; que ela ficou assustada; que ela pensou que era mentira; que pulou no pote, mas algemada; que já fazia uns meses que trabalhava lá (6 ou 7 meses); que ganhava 50 reais por faxina.

A testemunha comum, Policial Militar Jefferson dos Santos Pereira disse que estavam em patrulhamento; que visualizaram o local, que é conhecido; que viram um indivíduo saindo da casa pelo portão; que abordaram e ele estava com uma pedra de crack na mão; que ele falou que tinha acabado de comprar dos réus; que a porta estava aberta; que entraram para averiguar; que deram de cara com a Andreia que saiu correndo e tentou esconder um pote vermelho que estava em cima da pia; que os dois tentaram esconder o pote; que tinha uma quantidade de pedras de crack no mesmo formato do que foi vendido para o usuário; que ele falou que tinha comprado do Eduardo; que já tinha recebido denúncias; que já haviam abordado outras pessoas que deram as mesmas informações; que aparece mais o nome dela; que ela tem um bar; que fala na casa e no bar; que compram por uma janelinha; que eram mais de 90 pedras; que havia dinheiro trocado; que a porta da casa que estava aberta, de onde saiu o usuário; que não permitiram a entrada; que, quando entrou, a Andreia estava saindo do bar e foi de encontro com eles; que, na casa, estavam só os dois; dentro do bar, havia um rapaz consertando uma máquina.

A testemunha comum, Policial Militar Wanderson Ferreira de Souza disse que durante o patrulhamento, avistaram um indivíduo que estava deixando a residência da Andreia; que disse ter comprado a droga do Eduardo na residência; que efetuaram a abordagem; que foi localizada no interior da residência um pote contendo drogas e dinheiro; que já eram conhecidos os meios policiais por tráfico de drogas; que na época, havia notícias de que estavam traficando; que o local é a casa e o bar; que disseram que a droga não era deles; que a Andreia tentou esconder o pote; que ela tentou tirar da mão dele; que foi na esquina que pegaram com o Edvaldo; que não se recorda se o bar estava fechado ou aberto; que o portão da residência aberto; que o bar estava com uma porta lateral aberta; que realizaram a incursão na residência de imediato; que dentro do bar, havia só um rapaz fazendo manutenção; que não chegou no fundo da casa.

A testemunha da defesa Leandro Rodrigues Martins disse que estava presente no local dos fatos, mas dentro do bar, eles estavam na casa ao lado; que fazendo serviço; que chegou dois policiais apontando uma Ponto 40 mandando todos para fora; e ele perguntou "eu também?", e o policial respondeu que sim; que saiu para fora e ficou no sol, com as mãos para cima; que estava de uniforme e trabalhando; que ela estava pro lado de fora na área com uma criança de colo; que não conseguiu ver em qual lugar o Eduardo estava; que uns 5/10 minutos já estava no bar e fora do bar mais tempo; que pediu licença, entrou, sempre foi tratado com educação; que quando entrou na casa não tinha ninguém, só ele, o companheiro de viagem, a Andreia com uma criança de colo e o filho dela que estava na casa, ele que abriu o portão; que não tinha mais ninguém na residência.

Ao ser interrogada, a ré Andreia Aparecida Masse de Oliveira narrou que tem uma sala e que transformou ela em um bar; que no dia dos fatos, não abriu a porta do bar, porém tem a porta da sala que dá acesso para o quintal da casa; que no bar tem uma máquina de som; que no dia dos fatos, o Leandro veio para consertar ela; que estava com seu filho no colo no bar que dá acesso ao quintal; que foram surpreendidos por um barulho e não foi dito que era a PM, só viu um pulando o muro, que o outro abriu o portão para os outros entrar; que nenhum momento foi apresentado um mandado de busca e apreensão dentro da residência, entraram sem autorização; nisso que entraram, já me pegaram e algemaram; que foi nisso que a Jessica segurou o meu filho do colo; que estava algemada com o braço para frente; que a trouxeram para um corredor que tem para o quarto do filho; que é um quarto para o lado de fora; que para ela foi surpresa, porque estava dentro do bar como

Brian; que lá consertando a máquina; que se alguém chamou no portão, não ouviu; que nisso seu filho Eduardo já estava com os policiais; que viu um policial com um pote na mão; que eles falaram que tava todo mundo preso por trafico de droga; que algemada foi pegar o pote da mão do policial; que ficou surpresa ao saber daquilo; que eu queria saber o que tinha dentro daquele pote; que tem passagem sim, mas que não trafica, não rouba, cuida do filho; que a droga não estava dentro da minha casa, porque o quarto do Eduardo é para fora de casa; que não; que o filho corta cabelo e trabalha comigo; que de droga não, mas o bar ele frequenta sim; que conhece por ele ir no bar.

Ao ser interrogado, o réu Eduardo Aparecido Masse de Oliveira narrou que sua mãe não tem nada ver; que vendeu uma pedra de crack para o Indião; que estava com o pote de droga dentro do quarto; que ouviu um barulho e a mãe começou a perguntar o que estava acontecendo; que foi quando ele levantou e pegou o pote; que correu para cozinha; que se desesperou e deixou o pote em cima da pia; que foi quando viu sua mãe vindo algemada; que vendeu a pedra de crack por R\$ 10,00; que sim; que a mãe não sabia de nada; que quando vendeu a pedra de crack para o Indião, pediu para ele não comentar com ninguém, pois se a mãe souber, briga com ele; que não, foi a primeira vez que fez isso; porque precisava pagar pensão e ficou desesperado sem saber o que fazer; que tinha que vender a droga primeiro e depois devolver o dinheiro para o rapaz.

Os depoimentos prestados na fase judicial estão em consonância com as demais evidências colhidas dos autos e demonstram com segurança que Eduardo praticou o delito que lhe é atribuído.

A tese arguida pela defesa da nulidade das provas pela entrada ilegal dos policiais ao imóvel não deve prosperar, visto que o art. 33 da lei de drogas contém os verbos nucleares "guardar" e "ter em depósito" e que a indicação do usuário de que adquiriu os entorpecentes na casa dos réus pouco tempo antes de sua abordagem demonstra de forma segura que os acusados estavam em situação de flagrância de crime permanente, excepcionando a inviolabilidade do domicílio.

Neste sentido, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. ADEMAIS, SUPERVENIÊNCIA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TESE SUPERADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica e uníssona desta Casa é no sentido de que o delito de tráfico de entorpecentes, nas modalidades guardar, ter em depósito, expor à venda, transportar e trazer consigo, é crime permanente que, como tal, se protraí no tempo, sendo, portanto, prescindível a existência de mandado de busca e apreensão. Ademais, decretada a prisão preventiva, fica superada a alegação de nulidade do flagrante. Precedentes. Hipótese em que encontrados na residência do agravante mais de 5Kg de maconha. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 403.827/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 15/12/2017) - (grifo nosso).

Conforme apurado, na data dos fatos, policiais militares abordaram o usuário Edvaldo logo após ele sair de local onde recaíam denúncias de tráfico. Com ele foi encontrada uma pedra de crack e, questionado, admitiu que comprou o entorpecente de Eduardo pela quantia de R\$ 10,00. Em razão da informação do usuário e da situação de flagrância, adentraram na residência e apreenderam as drogas que estavam acondicionadas em um pote em posse de Eduardo.

Acerca dos depoimentos dos policiais, eis o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

"Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício

nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório" (STJ, Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, HCnº 115516/SP 03/02/2009).

Assim, o relato dos policiais que participaram da apreensão dos entorpecentes devem ser admitidos como meio de prova.

Além da certeza quanto à vinculação do acusado aos entorpecentes apreendidos, também não há dúvidas de que as substâncias se destinavam ao tráfico. A quantidade apreendida (97 pedra de crack, com peso líquido de 19,78), a forma de acondicionamento (dentro de um pote), bem como natureza da droga, evidencia que estas seriam destinadas ao comércio clandestino de entorpecentes. Com efeito, além das drogas, foram também encontrados R\$ 85,00 em notas diversas e mais algumas moedas.

Registre-se, que o réu Eduardo confessou espontaneamente em juízo, tornando possível o reconhecimento da atenuante.

No tocante à denunciada Andreia, não se ignora que ela estava presente no momento da apreensão das drogas e que era mãe de Eduardo, residindo ambos no local dos fatos. Porém, quanto a Andreia, o conjunto probatório se encontra fragilizado, pois não foram encontrados entorpecentes ou petrechos diretamente em sua posse, bem como a prova testemunhal não foi suficiente para demonstrar que era co-proprietária dos entorpecentes apreendidos ou que tenha participado do comércio ilícito. As testemunhas atestaram que ela possuía ocupação lícita e, até o presente momento, o único elemento a sugerir sua participação com os fatos é seu relacionamento de mãe e filho com Eduardo o que, no meu entender, é insuficiente para formar o juízo de condenação.

Assim, a pretensão punitiva procede unicamente em relação a Eduardo.

Passo à dosimetria.

Analisadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie. Possui maus antecedentes. Inexistem elementos desabonadores da personalidade do réu e de sua conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não destoam do esperado em delitos desta natureza. O comportamento da vítima não pode ser aferido nesse tipo de delito.

No tocante aos vetores do art. 42 da Lei 11.343/06, a quantidade não é expressiva a ensejar maior reprimenda. Contudo, a natureza dos entorpecentes, em razão do encontro da substância "crack", deve ser desvalorada, considerando que a forma de administração (aspiração pulmonar) é extremamente nociva ao usuário e à saúde pública em geral, além de apresentar um efeito viciante mais acentuado.

Assim, fixo a pena-base em 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão.

Na segunda etapa, presente a atenuante da confissão e da menoridade relativa, as quais, contudo, não podem ensejar a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, nos termos da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, resta a pena intermediária estabelecida em 5 anos de reclusão.

Na terceira fase, ausente causa de aumento de pena. Presente a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, pois o réu é primário, de bons antecedentes e não há prova de que integre organização criminosa ou que se dedique a atividades ilícitas. Considerando a ausência de ações penais em curso em desfavor do acusado (fl. 336), cabível a incidência da causa de diminuição

em seu grau máximo, de forma que fica a pena definitiva estabelecida em 1 ano e 8 meses de reclusão.

Fixo o regime inicial aberto.

A pena de multa, por simetria, fica estabelecida em 166 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Satisfeitos os requisitos do art. 44 do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por restritiva de direitos, o que faço para aplicar a prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 2 salários mínimos.

Ante o exposto julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER a acusada ANDRÉIA APARECIDA MASSE ORTIZ da imputação pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e CONDENAR o réu EDUARDO APARECIDO MASSE DE OLIVEIRA como incurso no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, no regime inicial aberto, além do pagamento de 166 dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 de salário mínimo vigente à época dos fatos, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de 2 salários mínimos.

Concedo aos acusados, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, os benefícios da justiça gratuita, razão pela qual deixo de condená-los nas custas processuais.

Defiro ao sentenciado o direito de apelar em liberdade.

Nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, de rigor a decretação do perdimento em favor da União do numerário e dos bens apreendidos (fls. 14/16).

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório do Distribuidor, ao IIRGD (NSCGH, arts. 393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGH, art. 398), expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Paraguacu Paulista, 14 de junho de 2022.

.DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA